



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ARAGÓN

LICENCIATURA EN DERECHO

**NATURALEZA JURÍDICA Y RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD
CONTRACTUAL DE LAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS
(*REPRESENTATIONS & WARRANTIES*) Y DE LAS CLÁUSULAS DE
INDEMNIZACIÓN (*CAP, BASKET, DE MINIMIS Y SURVIVAL*) EN LOS
CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE EMPRESAS (*SHARE
PURCHASE AGREEMENTS*) BAJO EL DERECHO MEXICANO**

T E S I S

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADO EN DERECHO**

P R E S E N T A

ELÍAS ALEJO CEDILLO

CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por su gracia, misericordia y fidelidad, que han sido fundamentales a lo largo de este proceso. Incluso en los momentos de incertidumbre, cansancio y dificultad, sostuvo mi vida y me permitió alcanzar esta etapa. Nunca me ha dejado y me ha enseñado a ser quien hoy soy. A Él sea toda la gloria y la honra.

A mi familia, por su amor, apoyo y confianza, pilares esenciales durante mi formación profesional y personal.

A la familia de Miros, que durante una etapa significativa de mi vida me brindó amistad, orientación, compañía y palabras de aliento.

A la señora Mirely, madre de Miros, por su cercanía, sus palabras llenas de sabiduría y el acompañamiento sincero que me ofreció. Su disposición para escuchar, aconsejar y estar presente dejó una huella profunda en mi vida, por lo que le expreso mi más sincero agradecimiento.

A Mamá Charo, mi abuela, por su ternura, su amor incondicional y su forma tan especial de acompañar. Su presencia fue un refugio de paz; sus palabras, un consuelo, y su cariño, una manifestación genuina de afecto. Agradezco profundamente haber formado parte de su vida y todo lo que me enseñó desde su experiencia y su bondad.

De manera especialmente significativa, agradezco a Miros, por ser una presencia esencial en mi vida y en este proceso. Su compañía, su forma de ver la vida y su apoyo constante fueron un impulso que fortaleció mi camino. En su persona encontré una motivación profunda y una inspiración que han marcado mi manera de esforzarme y de avanzar. Su influencia permanece como una parte significativa de mi historia, de lo que soy hoy y de lo que seré mañana.

Finalmente, expreso mi gratitud a todas aquellas personas que, de una u otra forma, contribuyeron a mi crecimiento académico, profesional y personal, y que hicieron posible la culminación de este trabajo.

ÍNDICE

AGRADECIMIENTOS	2
INTRODUCCIÓN	4
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	13
Pregunta de investigación	<i>En elaboración</i>
CAPÍTULO PRIMERO. EL SPA Y SU FUNCIÓN EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES	<i>En elaboración</i>
1.1 Concepto y caracteres del Share Purchase Agreement	<i>En elaboración</i>
1.2 Estructura: declaraciones y garantías, covenants, condiciones e indemnización	<i>En elaboración</i>
1.3 Función económica de las R&W: la asimetría informativa	<i>En elaboración</i>
1.4 La carta de revelaciones (disclosure letter)	<i>En elaboración</i>
CAPÍTULO SEGUNDO. ORIGEN DE LAS R&W EN EL COMMON LAW	<i>En elaboración</i>
2.1 Naturaleza de las representations y de las warranties	<i>En elaboración</i>
2.2 El régimen de indemnización: cap, basket, de minimis y survival	<i>En elaboración</i>
2.3 Sandbagging y seguro de R&W (W&I insurance)	<i>En elaboración</i>
2.4 La lógica contractual anglosajona	<i>En elaboración</i>
CAPÍTULO TERCERO. EL PROBLEMA DE RECEPCIÓN EN EL DERECHO MEXICANO	18
3.1 El trasplante jurídico de figuras contractuales anglosajonas	18
3.2 La libertad contractual y sus límites	19
3.3 El saneamiento por evicción	20
3.4 El saneamiento por vicios ocultos	21
3.5 Los vicios del consentimiento: error y dolo	22
3.6 Recapitulación y tránsito al problema de la naturaleza jurídica	23
CAPÍTULO CUARTO. NATURALEZA JURÍDICA DE LAS R&W EN EL DERECHO MEXICANO	<i>En elaboración</i>
CAPÍTULO QUINTO. EL RÉGIMEN DE INDEMNIZACIÓN FRENTE AL CÓDIGO CIVIL	<i>En elaboración</i>
CAPÍTULO SEXTO. DERECHO COMPARADO	<i>En elaboración</i>
CAPÍTULO SÉPTIMO. CONCLUSIONES Y PROPUESTA	<i>En elaboración</i>
FUENTES DE CONSULTA	<i>En elaboración</i>

I. INTRODUCCIÓN

Pocos fenómenos jurídicos revelan con tanta nitidez la tensión entre la realidad económica y la arquitectura conceptual del derecho como las operaciones de fusiones y adquisiciones de empresas, conocidas en la práctica internacional bajo el acrónimo anglosajón M&A. Detrás de esa expresión, en apariencia técnica y reservada a los grandes despachos corporativos, se esconde una de las manifestaciones más sofisticadas del tráfico jurídico contemporáneo: la transmisión del control de unidades productivas que, lejos de reducirse a la mera traslación de un bien, comprende la circulación de organizaciones complejas integradas por activos tangibles e intangibles, relaciones laborales, contratos en curso, contingencias fiscales, pasivos ocultos, propiedad intelectual, clientela, prestigio comercial y expectativas de rentabilidad futura. Quien adquiere una empresa no compra una cosa, sino un haz de relaciones jurídicas y económicas cuyo valor depende, en medida considerable, de información que se encuentra en poder del vendedor y que el comprador no puede verificar plenamente al momento de contratar. Es precisamente en esa asimetría informativa donde germina el conjunto de figuras contractuales que constituye el objeto del presente estudio.

La importancia económica de las operaciones de adquisición de empresas difícilmente puede exagerarse. En el plano mundial, las fusiones y adquisiciones representan uno de los principales mecanismos de reasignación de recursos productivos, de consolidación de mercados, de expansión transfronteriza de capitales y de reestructuración de grupos empresariales. A través de ellas se materializan estrategias de crecimiento que serían inviables por la vía del desarrollo orgánico, se facilita la entrada de inversión extranjera directa, se reorganizan sectores enteros de la economía y se transmite el control de compañías que emplean a miles de personas y generan cadenas de valor de amplio alcance. México no ha permanecido ajeno a este movimiento. La apertura comercial iniciada en las últimas décadas del siglo veinte, la integración del país a los grandes bloques de libre comercio, la modernización de su régimen de inversión extranjera y la creciente sofisticación de su sistema financiero han convertido al territorio nacional en un escenario habitual de operaciones de adquisición, tanto de capital nacional como internacional. La consecuencia natural de ese proceso ha sido la recepción, en la práctica jurídica mexicana, de los instrumentos contractuales que la comunidad financiera internacional ha decantado para documentar tales operaciones.

Entre esos instrumentos ocupa un lugar central el contrato de compraventa de acciones o de participaciones sociales, universalmente designado con el nombre inglés de Share Purchase Agreement, o SPA. Este contrato, que sirve de vehículo para transmitir el control de una sociedad mediante la adquisición de su capital social, se ha consolidado como el do-

cumento por excelencia de las operaciones de M&A. Sin embargo, su difusión en México no se ha producido a partir de un desarrollo doctrinal y legislativo autóctono, sino mediante la importación prácticamente íntegra de modelos elaborados conforme a la tradición jurídica anglosajona, y muy señaladamente conforme a la práctica corporativa estadounidense e inglesa. Los SPA que se firman cotidianamente en el país reproducen, con frecuencia traducidos del inglés y apenas adaptados, estructuras, cláusulas, categorías y lógicas que fueron concebidas para operar dentro del common law. El abogado mexicano que participa en una operación de esta naturaleza se encuentra, así, ante un contrato cuya morfología responde a una racionalidad jurídica distinta de aquella en la que fue formado, y cuyas piezas más características carecen de un correlato preciso en el derecho civil y mercantil nacional.

La influencia del common law sobre la contratación corporativa moderna constituye uno de los rasgos definitorios de la globalización jurídica. El predominio de los mercados financieros anglosajones, la hegemonía del idioma inglés como lengua franca de los negocios, la circulación internacional de los grandes despachos y la estandarización de las prácticas de financiamiento han propiciado que las categorías contractuales nacidas en Londres y en Nueva York se difundan a jurisdicciones de tradición romano-germánica que, como la mexicana, parten de presupuestos dogmáticos diferentes. Este fenómeno, que la doctrina comparada ha estudiado bajo la denominación de trasplante jurídico, plantea problemas de hondo calado, pues no se trata únicamente de traducir palabras, sino de injertar instituciones gestadas en un sistema que confía la creación del derecho a la jurisprudencia y a la autonomía de las partes, dentro de otro que reposa sobre la codificación, sobre categorías legales típicas y sobre principios imperativos de orden público. El SPA es, en este sentido, un producto paradigmático de la globalización contractual: un contrato cosmopolita que viaja de una jurisdicción a otra conservando su estructura, pero que al aterrizar en cada ordenamiento debe ser confrontado con el derecho local que habrá de regirlo e interpretarlo.

Dentro de la anatomía del SPA, dos conjuntos de cláusulas concentran la mayor densidad técnica y la mayor relevancia económica: las declaraciones y garantías, conocidas como representations and warranties, y el régimen de indemnización que se construye sobre ellas. Las declaraciones y garantías son afirmaciones de hecho mediante las cuales el vendedor describe el estado de la sociedad cuyas acciones transmite: la titularidad y validez de las acciones, la regularidad de la constitución social, la exactitud de los estados financieros, la inexistencia de pasivos ocultos, el cumplimiento de obligaciones fiscales y laborales, la vigencia de los contratos relevantes, la situación de la propiedad intelectual, la ausencia de litigios no revelados y un extenso catálogo de circunstancias de cuya veracidad depende el valor de lo adquirido. Mediante estas declaraciones, el vendedor traza un retrato jurídico y económico de la empresa, y se compromete a que ese retrato corresponda a la realidad. Su fun-

ción es esencialmente la de asignar el riesgo de la información asimétrica: dado que el comprador no puede conocer con certeza el verdadero estado del objeto adquirido, las declaraciones y garantías operan como un mecanismo de distribución contractual de las contingencias, en cuya virtud el vendedor asume frente al comprador las consecuencias de que la realidad no coincida con lo declarado.

La función económica de las declaraciones y garantías se comprende mejor cuando se advierte que el precio de una empresa se fija sobre la base de un conjunto de supuestos acerca de su situación patrimonial, financiera y jurídica. Si esos supuestos resultan falsos, el equilibrio de la operación se rompe: el comprador habrá pagado por una realidad que no existe. Las declaraciones y garantías cumplen, por ello, una doble misión. Por un lado, incentivan la revelación de información, pues obligan al vendedor a manifestar con precisión el estado de la sociedad y a develar, mediante el documento de revelaciones o disclosure letter, aquellas circunstancias que matizan o excepcionan sus declaraciones. Por otro lado, fijan el contenido de lo prometido y establecen el parámetro frente al cual habrá de medirse cualquier discrepancia ulterior entre lo declarado y lo real. La declaración cumple, así, una función probatoria y delimitadora: define qué se entiende incumplido y, por consiguiente, qué da lugar a responsabilidad.

El segundo conjunto de cláusulas, intimamente ligado al anterior, es el régimen de indemnización. Las declaraciones y garantías serían promesas vacías si su falsedad no acarreará consecuencias patrimoniales para quien las formuló. Por ello, los SPA articulan un sistema de indemnización mediante el cual el vendedor se obliga a resarcir al comprador por los daños derivados de la inexactitud de sus declaraciones, del incumplimiento de sus obligaciones o de la materialización de determinadas contingencias previamente identificadas. Este sistema no se limita a remitir genéricamente a la reparación del daño; antes bien, se construye con una precisión cuantitativa notable, mediante una serie de mecanismos cuya terminología, una vez más, procede del mundo anglosajón. La cláusula de cap establece un límite máximo a la responsabilidad del vendedor, de modo que su exposición patrimonial no exceda de cierta cuantía, frecuentemente referida a un porcentaje del precio. La cláusula de basket, o cesta, funciona como un umbral o franquicia: el vendedor solo responde una vez que los daños acumulados superan determinada cifra, evitando así que reclamaciones de escasa entidad activen la maquinaria indemnizatoria. La cláusula de minimis excluye las reclamaciones individuales que no alcancen un valor mínimo, depurando el sistema de incidencias triviales. Y la cláusula de survival, o supervivencia, fija el plazo durante el cual subsisten las declaraciones y garantías y, por tanto, la posibilidad de reclamar por su inexactitud, estableciendo un periodo de vigencia que puede ser distinto según la naturaleza de cada declaración.

El conjunto de estas estipulaciones configura un microsistema de responsabilidad diseñado por las partes para gobernar las consecuencias de la inexactitud de las declaraciones. Se trata, en rigor, de un régimen autónomo, minuciosamente calibrado, que pretende sustituir o desplazar la aplicación de las reglas generales que el ordenamiento prevé para los supuestos de incumplimiento contractual o de defectos de la cosa vendida. El comprador y el vendedor, asistidos por sus asesores, negocian con detalle cada uno de estos parámetros, pues de ellos depende la distribución final del riesgo económico de la operación. La práctica internacional ha desarrollado, además, instrumentos complementarios, como el seguro de declaraciones y garantías, que permite trasladar a un tercero asegurador el riesgo de la inexactitud, y figuras como el depósito en garantía o escrow, que aseguran la disponibilidad de fondos para responder de eventuales reclamaciones. Todo este andamiaje, sin embargo, descansa sobre un presupuesto que en el derecho anglosajón resulta pacífico, pero que en el derecho mexicano dista de serlo: la idea de que las partes pueden crear, mediante el contrato, un régimen completo y cerrado de responsabilidad que opere con relativa independencia de las categorías legales preexistentes.

He aquí el núcleo del problema que motiva esta investigación. En el sistema jurídico mexicano, de tradición romano-germánica y de base codificada, no existe una regulación expresa de las declaraciones y garantías ni de los mecanismos de indemnización pactados en los términos descritos. El Código Civil Federal y los códigos civiles de las entidades federativas, así como el Código de Comercio, regulan la compraventa, el incumplimiento de las obligaciones, los vicios del consentimiento y la responsabilidad civil, pero no contemplan, como categorías típicas, las figuras que el SPA importa del common law. El legislador mexicano no previó las *representations and warranties*; tampoco disciplinó las cláusulas de *cap, basket*, de *minimis* o *survival*. Estas figuras llegan al país por la vía de la práctica, insertas en contratos redactados conforme a moldes extranjeros, y se aplican confiando en que el principio de autonomía de la voluntad las dotará de eficacia. Pero esa confianza, por extendida que esté entre los operadores del mercado, no resuelve las preguntas dogmáticas de fondo que su recepción suscita.

La primera de esas preguntas atañe a la naturaleza jurídica misma de las declaraciones y garantías. ¿Qué son, en términos de las categorías del derecho civil mexicano? ¿Constituyen verdaderas obligaciones de garantía asumidas por el vendedor, de modo que su falsedad genere una responsabilidad de naturaleza contractual? ¿O deben entenderse como manifestaciones de voluntad que, de resultar falsas, vician el consentimiento del comprador por error o por dolo, con las consecuencias propias de la nulidad? ¿Acaso operan como una modalidad convencional del saneamiento, esto es, como una reconfiguración pactada de las garantías legales por evicción y por vicios ocultos que el ordenamiento ya impone al vende-

dor? ¿O bien estamos ante una obligación de garantía sui generis, atípica, que las partes crean al amparo de su libertad contractual y cuyo régimen se agota en lo pactado? La respuesta a estas interrogantes no es un mero ejercicio académico, pues de la calificación que se adopte dependen consecuencias prácticas de la mayor importancia: el plazo de prescripción aplicable, la carga de la prueba, los presupuestos de la responsabilidad, la posibilidad de exigir el cumplimiento o de resolver el contrato, la cuantificación del daño resarcible y, en definitiva, la eficacia o ineficacia del cuidadoso régimen que las partes diseñaron.

La segunda pregunta se refiere a la validez y exigibilidad del régimen de indemnización pactado frente a las normas del Código Civil. El ordenamiento mexicano reconoce con amplitud la autonomía de la voluntad y la libertad de configuración contractual. El Código Civil Federal autoriza a los contratantes a establecer las cláusulas que estimen convenientes, y el Código de Comercio consagra, para las convenciones mercantiles, el principio de que cada quien se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse. Sobre esa base, parecería que las cláusulas de limitación de responsabilidad, de umbrales mínimos y de plazos de supervivencia son perfectamente lícitas, en cuanto expresión de la libertad de los contratantes para distribuir entre sí los riesgos del negocio. Sin embargo, esa libertad no es ilimitada. El propio ordenamiento la subordina al respeto de las normas imperativas, del orden público y de las buenas costumbres, y declara nulos los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público. Surge entonces la cuestión de hasta dónde pueden las partes desplazar el régimen legal supletorio. ¿Puede la cláusula de survival acortar válidamente el plazo de prescripción que la ley concede para reclamar, o ampliarlo más allá de lo que el ordenamiento permite? ¿Puede el cap limitar la responsabilidad del vendedor incluso frente a conductas dolosas, o tropieza con la prohibición de renunciar anticipadamente a la acción derivada del dolo? ¿En qué medida la franquicia y el umbral mínimo son compatibles con el principio de reparación integral del daño? La tensión entre la autonomía de la voluntad y las normas imperativas constituye, en este punto, el eje sobre el que gira la discusión.

La ausencia de regulación expresa y la falta de consenso doctrinal sobre estos extremos generan un estado de incertidumbre que repercute directamente sobre la seguridad jurídica de los intervinientes en las operaciones de adquisición. El inversionista que adquiere una empresa mexicana, el comprador que confía en las declaraciones del vendedor y el vendedor que negocia los límites de su responsabilidad necesitan saber con razonable certeza cuál será la suerte de sus pactos si la operación termina en controversia. La paradoja es evidente: las cláusulas que con mayor esmero se negocian, y que precisamente persiguen aportar previsibilidad y delimitar el riesgo, son las que descansan sobre un fundamento jurídico menos firme dentro del derecho mexicano. Mientras la operación se desenvuelve con nor-

malidad, la cuestión permanece latente; pero cuando una declaración resulta falsa y el comprador acude a reclamar, el régimen contractual habrá de someterse al tamiz de un ordenamiento que no lo previó y que lo interpretará a partir de categorías ajenas a su origen. El resultado de ese encuentro es, hoy por hoy, difícilmente predecible.

La incertidumbre se agrava por la escasez de pronunciamientos judiciales nacionales que aborden de manera directa estas figuras. Buena parte de las controversias derivadas de operaciones de M&A se resuelven por la vía del arbitraje, en procedimientos de naturaleza confidencial cuyos laudos no se publican ni sientan criterios accesibles a la comunidad jurídica. La consecuencia es que los tribunales del orden común han tenido pocas oportunidades de calificar las declaraciones y garantías y de pronunciarse sobre la validez de los mecanismos de indemnización, lo que priva al sistema de los criterios orientadores que de ordinario aporta la jurisprudencia. El intérprete que se enfrenta a un litigio de esta clase carece, por ello, de un cuerpo consolidado de precedentes en el que apoyarse, y se ve obligado a reconstruir la solución a partir de los principios generales del derecho de las obligaciones, con el riesgo de interpretaciones divergentes y de resultados contradictorios. Esta orfandad jurisprudencial es, en sí misma, una de las dimensiones del problema y una de las razones que justifican el esfuerzo de sistematización que aquí se emprende.

La relevancia académica del tema deriva, en primer término, de este vacío. El estudio de las declaraciones y garantías y de las cláusulas de indemnización ofrece un campo fértil para el análisis dogmático, pues obliga a confrontar las categorías tradicionales del derecho civil con instituciones de cuño extranjero y a verificar su capacidad de respuesta ante problemas que el codificador no anticipó. Se trata, además, de un terreno en el que el derecho comparado adquiere especial valor heurístico: el examen del modo en que otros ordenamientos de tradición civil, como el español o los de la Unión Europea, han recibido estas figuras, así como del tratamiento que les dispensa el propio common law del que proceden, suministra elementos de juicio indispensables para construir una solución coherente con el sistema mexicano. La investigación que aquí se propone no aspira, por tanto, a describir un contrato de moda, sino a esclarecer un problema de teoría general del contrato y de la responsabilidad civil que se proyecta sobre una de las operaciones económicas más significativas de nuestro tiempo.

La relevancia práctica no es menor. La calificación que se atribuya a las declaraciones y garantías y la determinación de los límites de validez de las cláusulas de indemnización tienen consecuencias inmediatas para la redacción de los contratos, para la asesoría de las partes y para la resolución de las controversias. Un abogado que conozca con precisión cómo habrá de interpretarse un SPA bajo el derecho mexicano podrá redactar cláusulas más sólidas, anticipar los riesgos de ineficacia, ajustar los plazos y los límites a los márgenes que

el ordenamiento tolera y advertir a su cliente sobre los puntos en que el pacto pudiera resultar vulnerable. A la inversa, la ignorancia de estos extremos conduce a la importación acrítica de modelos extranjeros que, trasladados sin adaptación al contexto nacional, pueden resultar parcial o totalmente inoperantes cuando llegue el momento de hacerlos valer ante un tribunal mexicano. La presente investigación pretende, en este sentido, tender un puente entre la práctica corporativa y la dogmática civil, ofreciendo al operador jurídico un marco de análisis que le permita comprender, y no solo reproducir, los instrumentos con los que trabaja.

Determinar la naturaleza jurídica de las declaraciones y garantías es, en consecuencia, el primer paso necesario para resolver el problema. En el método del derecho civil, la calificación de una figura precede y condiciona la identificación de su régimen aplicable. Solo cuando se ha establecido qué es una determinada estipulación puede precisarse qué normas la gobiernan, qué remedios genera su incumplimiento y qué límites encuentra su eficacia. Por ello, la indagación sobre la naturaleza de las declaraciones y garantías no es una cuestión preliminar y prescindible, sino el verdadero centro de gravedad del estudio. De su esclarecimiento depende la posibilidad de ofrecer respuestas fundadas a las preguntas sobre prescripción, prueba, remedios y límites que la práctica plantea cotidianamente y que, hasta ahora, el derecho mexicano resuelve de manera vacilante.

La seguridad jurídica, valor cardinal de todo ordenamiento, se erige así en el horizonte último de la investigación. Para el inversionista que destina recursos a la adquisición de una empresa mexicana, para el comprador que asume el control de una sociedad confiando en la veracidad de lo declarado y para el vendedor que negocia los términos y los límites de su responsabilidad, la previsibilidad de las consecuencias jurídicas de sus pactos es condición indispensable de la confianza en el sistema. Un ordenamiento que no ofrece certeza sobre la eficacia de las cláusulas más relevantes de sus contratos más complejos desincentiva la inversión, encarece las operaciones y traslada al arbitraje internacional la resolución de controversias que bien podrían dirimirse conforme al derecho nacional. Aportar claridad sobre estos extremos no es, por ello, un objetivo meramente teórico, sino una contribución al fortalecimiento del entorno jurídico en el que se desenvuelve la actividad económica del país.

La utilidad de la investigación para la práctica corporativa mexicana se proyecta, finalmente, sobre la propia evolución del derecho nacional. El esfuerzo por encuadrar las declaraciones y garantías y las cláusulas de indemnización dentro de las categorías del derecho civil y mercantil vigente, así como por delimitar el espacio que la autonomía de la voluntad ocupa frente a las normas imperativas, contribuye a depurar conceptualmente una práctica que ha crecido más por imitación que por reflexión. Establecer criterios de interpretación,

identificar los límites de validez de los pactos y proponer, en su caso, las mejores prácticas de redacción que permitan blindar estas cláusulas frente a un eventual escrutinio judicial son aportaciones que trascienden el interés académico y se traducen en herramientas concretas para quienes ejercen la profesión. En esa medida, el presente trabajo se inscribe en la mejor tradición de la ciencia jurídica, que no se contenta con describir las instituciones, sino que aspira a comprenderlas, a ordenarlas y a perfeccionarlas.

Para situar adecuadamente las figuras que constituyen el objeto de este estudio, conviene recordar que el SPA no es un acto instantáneo, sino el resultado de un proceso negociador escalonado cuya comprensión ilumina la función de las declaraciones y garantías. La operación suele iniciarse con documentos preliminares, como la carta de intención o el memorando de entendimiento, que fijan los grandes parámetros del negocio proyectado; prosigue con una fase de auditoría legal, contable y fiscal, conocida como *due diligence*, en la que el comprador examina la documentación de la sociedad objetivo para formarse un juicio sobre su verdadera situación; y desemboca en la firma del contrato y, eventualmente, en un cierre posterior en el que se cumplen las condiciones suspensivas y se consuma la transmisión. En ese itinerario, las declaraciones y garantías cumplen una función que la *due diligence* no puede sustituir por completo, pues por minuciosa que sea la revisión, el comprador nunca logra disipar toda la incertidumbre sobre el estado de la empresa. Las declaraciones operan, entonces, como el complemento contractual de la auditoría: cubren aquello que la revisión no alcanzó a descubrir y trasladan al vendedor el riesgo de lo que permaneció oculto. De este modo, la auditoría y las declaraciones funcionan como dos instrumentos complementarios de gestión de la asimetría informativa, y solo se comprenden cabalmente cuando se las examina en su mutua relación.

La propia denominación de la figura encierra una clave de su naturaleza que merece atención. En el derecho anglosajón, las *representations* y las *warranties* son categorías distintas: la *representation* es una afirmación de hecho que induce a la otra parte a contratar y cuyo carácter falso abre la vía de la acción por *misrepresentation*, próxima a los vicios del consentimiento; la *warranty*, en cambio, es una promesa contractual cuyo incumplimiento da lugar a una acción por daños de naturaleza contractual. La práctica fusionó ambas en una fórmula conjunta, y el español las tradujo como declaraciones y garantías, expresión que arrastra esa ambivalencia de origen. Esa dualidad no es un mero accidente terminológico, sino el reflejo de una tensión conceptual que reaparece cuando se intenta calificar la figura conforme al derecho mexicano, pues según se acentúe el componente de afirmación de hecho o el de promesa de garantía, la solución se inclinará hacia el régimen de los vicios del consentimiento o hacia el de la responsabilidad por incumplimiento. Comprender el doble linaje de la institución es, por ello, indispensable para abordar con rigor el problema de su na-

turalidad.

A esa complejidad se añade la estrecha vinculación entre las declaraciones y el principio de buena fe que informa la contratación. El documento de revelaciones, mediante el cual el vendedor exceptúa de sus declaraciones aquellas circunstancias que da a conocer al comprador, redistribuye el riesgo de manera precisa: lo revelado deja de comprometer la responsabilidad del vendedor, mientras que lo silenciado u ocultado la agrava. La interacción entre la revelación, el conocimiento del comprador y la exigibilidad de la indemnización plantea problemas delicados, como el del comprador que reclama por la inexactitud de una declaración cuyo carácter falso conocía al contratar, cuestión que el derecho anglosajón discute bajo la rúbrica del *sandbagging* y que en el derecho mexicano debe resolverse a la luz de la buena fe y de la doctrina de los actos propios. Estos extremos confirman que las declaraciones y garantías no son cláusulas aisladas, sino piezas de un sistema contractual articulado cuya lógica solo se aprehende considerando el conjunto.

Conviene precisar, desde estas páginas iniciales, el alcance y los límites del estudio. La investigación se concentra en las declaraciones y garantías y en las cláusulas de indemnización tal como se incorporan a los contratos de compraventa de acciones o participaciones sociales, esto es, en el SPA entendido como vehículo de transmisión del control societario, y aborda el problema desde la perspectiva del derecho mexicano vigente, sin perjuicio del recurso al derecho comparado como instrumento de análisis. No se pretende agotar el tratamiento de la totalidad de las cláusulas que integran un SPA, ni examinar las particularidades de los sectores regulados, ni desarrollar las cuestiones fiscales o de competencia económica que acompañan a estas operaciones, salvo en la medida en que resulten indispensables para comprender el régimen de responsabilidad. El propósito es, más modesto pero más profundo: ofrecer una caracterización dogmática rigurosa de dos figuras nucleares y extraer de ella las consecuencias prácticas que de ordinario quedan sin resolver. A partir de este planteamiento general, el siguiente apartado precisa los términos del problema de investigación y formula la interrogante que habrá de guiar el desarrollo del trabajo.

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema que da origen a esta investigación nace de un desencuentro entre dos lógicas jurídicas que conviven, sin haberse reconciliado, en la práctica corporativa mexicana. De un lado se encuentra la realidad de un mercado que documenta sus operaciones de adquisición de empresas con contratos de estirpe anglosajona, redactados conforme a moldes que la comunidad financiera internacional ha estandarizado y que reproducen categorías propias del common law. Del otro se halla un ordenamiento de tradición romano-germánica, codificado y vertebrado por categorías típicas y por principios imperativos, que no previó esas figuras y que, sin embargo, está llamado a regirlas e interpretarlas cuando la operación se somete al derecho mexicano. El contrato de compraventa de acciones, o Share Purchase Agreement, es el escenario donde ese desencuentro se manifiesta con mayor intensidad, y dentro de él, las declaraciones y garantías y las cláusulas de indemnización son las piezas que con mayor crudeza ponen a prueba la capacidad del sistema nacional para absorber lo que la práctica le impone.

La recepción de figuras contractuales anglosajonas en el sistema mexicano no es, en sí misma, un fenómeno anómalo ni indeseable. Todo ordenamiento vivo incorpora soluciones foráneas cuando estas responden a necesidades reales del tráfico, y la circulación internacional de modelos contractuales es consustancial a una economía globalizada. El problema no radica en la recepción, sino en el modo en que esta se ha producido: por la vía de la imitación práctica, sin mediación legislativa ni decantación doctrinal suficiente, y con frecuencia mediante la traducción literal de cláusulas concebidas para operar dentro de un sistema jurídico distinto. El resultado es un trasplante incompleto, en el que la forma del contrato se importa íntegramente, pero el sustrato normativo que en su origen le daba sentido permanece en la jurisdicción de procedencia. Las declaraciones y garantías presuponen, en el common law, un entramado de remedios, plazos y doctrinas que el derecho mexicano no reproduce; cuando esas cláusulas se insertan en un contrato regido por el derecho nacional, quedan privadas de su contexto original y deben buscar acomodo en categorías que no fueron diseñadas para ellas. La pregunta por cómo se realiza ese acomodo, y por si es siquiera posible realizarlo sin desnaturalizar la figura o sin vulnerar normas imperativas, es el primer estrato del problema.

La falta de regulación expresa de las declaraciones y garantías es el dato normativo del que parte toda la discusión. Ni el Código Civil Federal ni los ordenamientos civiles de las entidades federativas, ni el Código de Comercio, contemplan las representations and warranties como categoría contractual típica. No existe una norma que defina qué son, que pre-

cise sus efectos, que fije el plazo durante el cual pueden invocarse o que determine los remedios que su inexactitud genera. El legislador disciplinó la compraventa y previó, para ella, las garantías de saneamiento por evicción y por vicios ocultos; reguló los vicios del consentimiento y las consecuencias del error y del dolo; estableció el régimen general del incumplimiento de las obligaciones y de la responsabilidad civil. Pero no anticipó que las partes diseñarían un catálogo extenso y detallado de afirmaciones sobre el estado de la sociedad transmitida, ni que sobre ese catálogo construirían un régimen propio de consecuencias patrimoniales. Las declaraciones y garantías son, desde la perspectiva del derecho positivo mexicano, una figura atípica, y su tratamiento debe reconstruirse a partir de los principios generales y de las categorías afines, con todas las dificultades que esa reconstrucción comporta.

Idéntica carencia se observa respecto de los mecanismos de indemnización. Las cláusulas de cap, basket, de minimis y survival no encuentran reconocimiento ni disciplina expresa en la legislación nacional. El ordenamiento conoce la pena convencional, la limitación de responsabilidad, la prescripción de las acciones y el principio de reparación del daño, pero no ha tipificado los concretos mecanismos mediante los cuales los SPA limitan cuantitativamente la responsabilidad del vendedor, establecen umbrales y franquicias o fijan plazos de supervivencia distintos de los legales. Estas estipulaciones se aplican confiando en que la autonomía de la voluntad las ampara, pero esa confianza no ha sido contrastada con un análisis sistemático de su compatibilidad con las normas imperativas que limitan la libertad contractual. La consecuencia es que el régimen indemnizatorio más cuidadosamente negociado descansa, en última instancia, sobre un fundamento jurídico que la doctrina no ha precisado y que la jurisprudencia no ha confirmado.

De esa doble carencia deriva la incertidumbre sobre la naturaleza jurídica de las figuras, que constituye el corazón del problema. Las declaraciones y garantías admiten, en efecto, más de una lectura dentro de las categorías del derecho civil mexicano, y cada lectura conduce a un régimen distinto. Cabe entenderlas, en primer lugar, como obligaciones contractuales autónomas de garantía, asumidas por el vendedor en ejercicio de la libertad de configuración del contrato, cuya inexactitud generaría una responsabilidad de naturaleza contractual sujeta al régimen general del incumplimiento. Cabe interpretarlas, en segundo lugar, como una modalidad convencional del saneamiento, esto es, como una reconfiguración pactada de las garantías legales por evicción y por vicios ocultos que el ordenamiento ya impone al vendedor, lo que las sujetaría a los plazos y a las reglas propias de esas acciones, en la medida en que no hayan sido válidamente modificadas. Cabe concebirlas, en tercer lugar, como manifestaciones de hecho que, de resultar falsas, vician el consentimiento del comprador por error o por dolo, abriendo la vía de la nulidad relativa con sus consecuencias restitutorias e indemnizatorias. Y cabe, en fin, sostener su carácter *sui generis*, como fi-

gura atípica cuyo régimen se agota en lo pactado, salvo en aquello que contradiga normas imperativas. La coexistencia de estas interpretaciones, todas ellas defendibles a partir del material normativo disponible, es la expresión más acabada de la incertidumbre que se denuncia.

Las posibles interpretaciones desde el derecho civil mexicano no son equivalentes ni intercambiables, pues de cada una se siguen consecuencias prácticas divergentes que afectan de manera decisiva la posición de las partes. Si las declaraciones y garantías se califican como obligaciones contractuales de garantía, la acción para reclamar su inexactitud se someterá, en principio, al plazo general de prescripción de las acciones personales, la carga de la prueba se distribuirá conforme a las reglas del incumplimiento y el comprador podrá pretender la reparación del daño en los términos pactados. Si, en cambio, se las asimila al saneamiento, entrarán en juego los plazos breves y las reglas específicas que el ordenamiento prevé para la evicción y para los vicios ocultos, lo que podría reducir drásticamente el tiempo disponible para reclamar y alterar los presupuestos de la acción. Y si se las trata como vicios del consentimiento, el remedio ya no será la indemnización contractual, sino la nulidad del contrato, con la consiguiente restitución de las prestaciones y un régimen probatorio y temporal por completo distinto. La calificación, lejos de ser una disquisición teórica, determina qué puede reclamar el comprador, en qué plazo, con qué prueba y con qué resultado. La ausencia de una respuesta consolidada sobre este punto coloca a las partes en una situación de inseguridad estructural.

A esa incertidumbre dogmática se suman los problemas prácticos que enfrentan compradores y vendedores. El comprador que descubre, después del cierre, que una declaración era falsa necesita saber si su reclamación se rige por el plazo que las partes pactaron en la cláusula de supervivencia o por el plazo legal que pudiera resultar aplicable con independencia de lo convenido; si el límite cuantitativo acordado lo vincula incluso cuando el daño real es mayor; y si el umbral mínimo le impide reclamar contingencias que individualmente no lo alcanzan, aunque en conjunto erosionen el valor de su adquisición. El vendedor, por su parte, necesita certeza sobre la firmeza de los límites que negoció, pues toda su exposición patrimonial posterior a la operación depende de que el cap y la survival sean respetados; si esos límites pudieran ser desbordados por la aplicación de normas imperativas, la operación que creyó cerrada permanecería abierta más allá de lo previsto y por cuantías superiores a las asumidas. Ambas partes, en suma, contratan sobre la base de un reparto del riesgo cuya eficacia jurídica no está garantizada, lo que introduce un factor de imprevisibilidad en el centro mismo de la operación.

Los problemas de interpretación judicial potenciales agravan este panorama. Cuando una controversia derivada de un SPA llega a conocimiento de un tribunal mexicano, el juz-

gador se enfrenta a un contrato cuya terminología y estructura proceden de un sistema ajeno y debe traducirlas a las categorías de su propio ordenamiento para resolver. Esa labor de traducción no es neutral: según el tribunal acentúe el componente de garantía o el de afirmación de hecho, según privilegie la autonomía de la voluntad o la protección de las normas imperativas, según interprete restrictiva o extensivamente los límites de la libertad contractual, el resultado podrá variar de manera significativa. La inexistencia de criterios jurisprudenciales consolidados sobre estas figuras priva al juzgador de pautas orientadoras y multiplica el riesgo de soluciones divergentes ante supuestos análogos. A ello se añade que buena parte de estas controversias se sustraen al conocimiento de los tribunales mediante cláusulas de arbitraje, cuyos laudos confidenciales no contribuyen a la formación de un cuerpo de doctrina accesible. El sistema carece, por tanto, de los mecanismos que de ordinario reducen la incertidumbre interpretativa, y la previsibilidad que las partes buscaban al pactar se ve comprometida precisamente en el momento en que más la necesitan.

En el trasfondo de todas estas dificultades late la tensión entre la autonomía de la voluntad y las normas imperativas, que es el problema de fondo que las cláusulas examinadas plantean. El derecho mexicano reconoce con amplitud la libertad de los contratantes para configurar el contenido de sus convenios y para distribuir entre sí los riesgos del negocio, y esa libertad alcanza su máxima expresión en el ámbito mercantil, donde rige el principio de que cada quien se obliga en la manera y términos en que aparezca que quiso obligarse. Pero esa libertad no es absoluta: encuentra su límite en las normas de orden público, en las disposiciones imperativas y en la prohibición de pactos que contraríen el interés general o que persigan eludir la aplicación de la ley. El interrogante es, entonces, hasta dónde puede llegar la autonomía de la voluntad al diseñar el régimen de las declaraciones y garantías y de la indemnización. ¿Pueden las partes acortar o ampliar libremente el plazo de prescripción mediante la cláusula de supervivencia, o tropieza ese pacto con el carácter indisponible de las normas sobre prescripción? ¿Puede el cap limitar la responsabilidad del vendedor incluso frente al dolo, o se opone a ello la regla que impide renunciar anticipadamente a la acción derivada de la mala fe? ¿Son compatibles la franquicia y el umbral mínimo con el principio de reparación del daño, o lo erosionan en una medida que el ordenamiento no tolera? Resolver estas cuestiones exige trazar con precisión la frontera entre lo que las partes pueden válidamente pactar y lo que el ordenamiento les sustrae, frontera que hoy permanece imprecisa.

La ausencia de consenso doctrinal sobre el fundamento jurídico de estas figuras cierra el círculo del problema. La doctrina mexicana se ha ocupado de las declaraciones y garantías y de las cláusulas de indemnización de manera fragmentaria y, en buena medida, desde la perspectiva de la práctica antes que desde la dogmática. No existe un acuerdo sobre su naturaleza, ni una sistematización de los límites que la autonomía de la voluntad encuentra

al configurarlas, ni una doctrina consolidada que oriente al intérprete. Los autores que han abordado la materia lo han hecho con frecuencia describiendo la práctica internacional o trasladando las soluciones del derecho comparado, sin confrontarlas de manera rigurosa con las categorías y con las normas imperativas del derecho nacional. Esa falta de consenso no es un defecto menor: priva a los operadores de un marco conceptual compartido, alimenta la inseguridad jurídica y deja la solución de cada caso a merced de la sensibilidad del intérprete de turno. La construcción de una respuesta dogmáticamente fundada, anclada en el derecho mexicano vigente y enriquecida por el derecho comparado, se presenta así como una necesidad tanto teórica como práctica.

El problema, en definitiva, puede formularse en los siguientes términos. La práctica corporativa mexicana emplea de manera generalizada contratos de compraventa de empresas que incorporan declaraciones y garantías y mecanismos de indemnización de origen anglosajón, cuya naturaleza jurídica no ha sido determinada por el legislador, precisada por la doctrina ni confirmada por la jurisprudencia, y cuya validez y eficacia dependen de una compatibilidad con las normas imperativas del ordenamiento nacional que no ha sido suficientemente esclarecida. De esa indeterminación derivan consecuencias prácticas relevantes en materia de prescripción, prueba, remedios y límites de la responsabilidad, así como un déficit de seguridad jurídica que afecta por igual a compradores, vendedores e inversionistas. Esclarecer la naturaleza jurídica de estas figuras y delimitar el espacio que la autonomía de la voluntad ocupa frente a las normas imperativas es, por tanto, condición necesaria para dotar de previsibilidad a una de las operaciones económicas más relevantes del tráfico contemporáneo.

A partir de las consideraciones anteriores, la presente investigación se propone responder a la siguiente pregunta: en un sistema jurídico de tradición romano-germánica que no las regula de manera expresa, ¿cuál es la naturaleza jurídica de las declaraciones y garantías incorporadas a los contratos de compraventa de empresas, y en qué medida resulta válido y exigible, frente a las normas imperativas del Código Civil y de la legislación mercantil mexicana, el régimen de indemnización pactado mediante las cláusulas de cap, basket, de minimis y survival?

CAPÍTULO TERCERO

EL PROBLEMA DE RECEPCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES Y GARANTÍAS EN EL DERECHO MEXICANO

El tránsito desde el planteamiento del problema hacia su análisis dogmático exige descender del plano de la descripción al del derecho positivo. Hasta aquí se ha sostenido que las declaraciones y garantías y las cláusulas de indemnización constituyen figuras importadas del common law cuya naturaleza y eficacia no han sido resueltas por el ordenamiento mexicano. Corresponde ahora confrontar esas figuras con las normas vigentes que habrán de regirlas, pues solo el contraste con el texto de la ley permite determinar si el sistema nacional dispone de categorías capaces de alojarlas o si, por el contrario, su recepción tropieza con límites que la práctica suele pasar por alto. El presente capítulo inicia ese examen describiendo el fenómeno del trasplante jurídico y analizando, una por una, las instituciones del derecho civil y mercantil mexicano que guardan mayor proximidad con las representations and warranties: la libertad de configuración del contrato y sus límites, el saneamiento por evicción, el saneamiento por vicios ocultos y los vicios del consentimiento.

3.1 El trasplante jurídico de figuras contractuales anglosajonas

La doctrina comparada denomina trasplante jurídico al fenómeno por el cual una institución gestada en un ordenamiento se incorpora a otro distinto. El SPA mexicano es un ejemplo paradigmático: su estructura, su terminología y su lógica proceden del derecho angloamericano, mientras que la ley que habrá de interpretarlo pertenece a la tradición romano-germánica. El problema no es la importación en sí, sino que esta se ha producido por la vía de la práctica, sin mediación legislativa, de modo que las cláusulas conservan su forma originaria pero quedan privadas del entramado de remedios, plazos y doctrinas que en su sistema de origen les daban sentido. La tarea del intérprete consiste, entonces, en reconstruir ese sentido a partir de las categorías propias del derecho mexicano, verificando hasta qué punto resultan idóneas para gobernar una figura que no fue pensada para ellas.

El punto de partida de ese análisis es la determinación del régimen aplicable al contrato. Tratándose de la compraventa de acciones de una sociedad mercantil con propósito especulativo, el SPA es un acto de comercio, por lo que se rige por el Código de Comercio y,

supletoriamente, por la legislación civil federal. Esta doble fuente normativa no es un dato menor: condiciona los principios que disciplinan la autonomía de la voluntad, los remedios disponibles y los plazos de prescripción, como se verá a lo largo del capítulo.

3.2 La libertad contractual y sus límites

El primer fundamento al que suele acudir para sostener la validez de las declaraciones y garantías y del régimen de indemnización pactado es el principio de autonomía de la voluntad. En materia mercantil, este principio alcanza su expresión más amplia en el artículo 78 del Código de Comercio, conforme al cual:

En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.

En el ámbito civil supletorio, la libertad de configuración encuentra apoyo en el artículo 1839 del Código Civil Federal, que reconoce a los contratantes la facultad de incorporar al contrato el contenido que estimen conveniente:

Los contratantes pueden poner las cláusulas que crean convenientes; pero las que se refieran a requisitos esenciales del contrato, o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se tendrán por puestas aunque no se expresen, a no ser que las segundas sean renunciadas en los casos y términos permitidos por la ley.

A su vez, el artículo 1796 del mismo ordenamiento consagra la fuerza obligatoria del contrato y, de manera decisiva para el problema que nos ocupa, extiende el vínculo más allá de lo expresamente pactado, integrándolo con la buena fe, el uso y la ley:

Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde que se perfeccionan obligan a los contratantes, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.

De estos preceptos se desprende que las partes de un SPA pueden, en principio, asumir las obligaciones de garantía que tengan por convenientes y articular sobre ellas un régimen de consecuencias patrimoniales a su medida. Sin embargo, esa libertad no es absoluta. El propio sistema la subordina al respeto de las normas imperativas y del orden público, según resulta del artículo 8 del Código Civil Federal:

Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario.

La tensión entre la autonomía de la voluntad y las normas imperativas, anunciada en el planteamiento del problema, se concreta así en una cuestión de límites: hasta dónde pueden los contratantes desplazar el régimen legal supletorio mediante sus pactos. Determinar esos límites exige examinar las figuras del derecho civil que el SPA roza al regular las consecuencias de la inexactitud de las declaraciones, a saber, el saneamiento y los vicios del consentimiento.

3.3 El saneamiento por evicción

La primera figura civil cercana a las declaraciones y garantías es la obligación de saneamiento por evicción, que el ordenamiento impone al enajenante con independencia de todo pacto. El artículo 2120 del Código Civil Federal es categórico:

Todo el que enajena está obligado a responder de la evicción, aunque nada se haya expresado en el contrato.

El supuesto que activa esta garantía aparece definido en el artículo 2119, que circunscribe la evicción a la privación del bien por sentencia firme fundada en un derecho anterior a la adquisición:

Habrà evicción cuando el que adquirió alguna cosa fuere privado del todo o parte de ella por sentencia que cause ejecutoria, en razón de algún derecho anterior a la adquisición.

La relevancia de esta figura para el SPA es doble. Por un lado, demuestra que el derecho mexicano conoce y regula obligaciones de garantía que operan como un elemento natural del contrato, lo que ofrece un primer punto de anclaje para las declaraciones sobre la titularidad de las acciones transmitidas. Por otro lado, y de manera aún más significativa, el artículo 2121 reconoce expresamente que el régimen de evicción es disponible para las partes, que pueden agravarlo, atenuarlo o incluso excluirlo:

Los contratantes pueden aumentar o disminuir convencionalmente los efectos de la evicción, y aun convenir en que ésta no se preste en ningún caso.

Esta norma resulta de la mayor importancia para la tesis, pues constituye un reconocimiento legislativo de que las garantías propias de la enajenación admiten configuración

convencional. Si la ley permite a las partes modular e incluso suprimir una garantía que ella misma impone, con mayor razón habrá de admitirse que pacten garantías adicionales y que regulen sus consecuencias, como hacen las declaraciones y garantías del SPA. No obstante, conviene advertir que el ámbito propio de la evicción —la privación del bien por un derecho de tercero— es más estrecho que el de las declaraciones y garantías, que cubren además la situación financiera, fiscal, laboral y contractual de la sociedad. La evicción, por tanto, ilumina la lógica de la garantía convencional, pero no agota el contenido de las representations and warranties.

3.4 El saneamiento por vicios ocultos

La segunda figura civil próxima es el saneamiento por vicios ocultos, que protege al adquirente frente a los defectos no aparentes de la cosa. El artículo 2142 del Código Civil Federal delimita la obligación en los contratos conmutativos:

En los contratos conmutativos, el enajenante está obligado al saneamiento por los defectos ocultos de la cosa enajenada que la haga impropia para los usos a que se la destina, o que disminuyan de tal modo este uso, que a haberlo conocido el adquirente no hubiere hecho la adquisición o habría dado menos precio por la cosa.

El régimen excluye, sin embargo, los defectos aparentes y aquellos que un adquirente perito hubiera debido conocer, conforme al artículo 2143:

El enajenante no es responsable de los defectos manifiestos o que estén a la vista, ni tampoco de los que no lo están, si el adquirente es un perito que por razón de su oficio o profesión debe fácilmente conocerlos.

Esta exclusión guarda un paralelismo notable con la función de la auditoría legal (due diligence) y de la carta de revelaciones en el SPA: lo que el comprador conoció o debió conocer deja de comprometer la responsabilidad del vendedor. Frente al vicio oculto, el artículo 2144 confiere al adquirente una doble vía de reparación, la acción redhibitoria y la estimatoria o quanti minoris:

En los casos del artículo 2142, puede el adquirente exigir la rescisión del contrato y el pago de los gastos que por él hubiere hecho, o que se le rebaje una cantidad proporcionada del precio, a juicio de peritos.

El obstáculo decisivo que esta figura plantea reside en su brevísimo plazo de ejercicio. El artículo 2149 sujeta las acciones nacidas del saneamiento por vicios ocultos a una caducidad de seis meses:

Las acciones que nacen de lo dispuesto en los artículos del 2142 al 2148, se extinguen a los seis meses, contados desde la entrega de la cosa enajenada, sin perjuicio de lo dispuesto en el caso especial a que se refieren los artículos 2138 y 2139.

Aquí aflora una de las tensiones centrales anunciadas en el planteamiento. Si las declaraciones y garantías se calificaran como una manifestación del saneamiento por vicios ocultos, las reclamaciones del comprador quedarían sujetas a un plazo de apenas seis meses, radicalmente inferior a los periodos de supervivencia que la práctica del SPA pacta para las declaraciones —con frecuencia de doce a veinticuatro meses para las ordinarias y plazos mayores para las fundamentales y fiscales—. La caracterización de la figura no es, pues, una disquisición teórica: determina si el régimen contractual de survival opera válidamente o si choca con un plazo legal de caducidad que las partes no podrían ampliar libremente.

3.5 Los vicios del consentimiento: error y dolo

La tercera figura civil relevante no atañe al cumplimiento del contrato, sino a su formación. Si las declaraciones del vendedor se conciben como afirmaciones de hecho que determinan la decisión de contratar del comprador, su falsedad podría analizarse como un vicio del consentimiento. El artículo 1812 del Código Civil Federal enuncia el principio:

El consentimiento no es válido si ha sido dado por error, arrancado por violencia o sorprendido por dolo.

El dolo, particularmente pertinente cuando el vendedor conoce la inexactitud de lo que declara, se define en el artículo 1815:

Se entiende por dolo en los contratos, cualquiera sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguno de los contratantes; y por mala fe, la disimulación del error de uno de los contratantes, una vez conocido.

Y el artículo 1816 precisa el efecto invalidante del dolo cuando ha sido la causa determinante del acto:

El dolo o mala fe de una de las partes y el dolo que proviene de un tercero, sabiéndolo aquélla, anulan el contrato si ha sido la causa determinante de este acto jurídico.

Esta vía conduce a consecuencias por completo distintas de las propias del incumplimiento contractual: no a la indemnización pactada conforme al régimen de cap y basket, sino a la nulidad del contrato y a la restitución de las prestaciones, con su propio régimen

probatorio y temporal. La eventual caracterización de la declaración falsa como dolo plantea, además, un problema adicional que la práctica anglosajona discute bajo la rúbrica del sandbagging y que en el derecho mexicano debe resolverse a la luz de la buena fe consagrada en el artículo 1796: la situación del comprador que reclama por la inexactitud de una declaración cuyo carácter falso conocía al contratar.

3.6 Recapitulación y tránsito al problema de la naturaleza jurídica

El recorrido anterior permite extraer una conclusión provisional. El derecho mexicano no desconoce las obligaciones de garantía ni la protección frente a la información asimétrica; antes bien, dispone de un repertorio de figuras —la garantía convencional de evicción, el saneamiento por vicios ocultos y los vicios del consentimiento— que guardan parentesco con las declaraciones y garantías del SPA. Sin embargo, ninguna de ellas coincide plenamente con la figura anglosajona: la evicción se ciñe a la privación del bien por un tercero; el saneamiento por vicios ocultos somete la reclamación a un plazo de seis meses incompatible con la práctica del SPA; y los vicios del consentimiento conducen a la nulidad y no a la indemnización pactada. Cada caracterización arrastra, además, un plazo de prescripción distinto, oscilando entre la caducidad semestral del saneamiento, los diez años de la prescripción civil ordinaria del artículo 1159 del Código Civil Federal —"Fuera de los casos de excepción, se necesita el lapso de diez años, contado desde que una obligación pudo exigirse, para que se extinga el derecho de pedir su cumplimiento"— y la prescripción mercantil ordinaria del artículo 1047 del Código de Comercio, que se completa igualmente por el transcurso de diez años. La pregunta por la naturaleza jurídica de las representations and warranties, lejos de resolverse, se revela así como el verdadero núcleo del problema, cuyo desarrollo se aborda en el capítulo siguiente.